

1500061-21.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... dos fatos, para o crime de associação para o tráfico.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Em que pese os argumentos da defesa, não há confissão quanto ao tráfico, sendo incabível o reconhecimento da confissão, conforme enunciado da súmula n.º 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracaí-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500061-21.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500061-21.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020111/2022 - DEL.POL.MARACAI, 22589323 - DEL.POL.MARACAI, 33/22/112 - DEL.POL.MARACAI, 2020111 - DEL.POL.MARACAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Jamily Mrachna Nunes de Souza e Caio Henrique Souza de Oliveira foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas na denúncia, associaram-se para o fim de juntos cometerem o crime de tráfico de drogas.

Ainda, na tarde de 22 de janeiro de 2022, por volta das 16h10, na Chácara Santana, situada à Estrada das Pitangueira, 100, nesta cidade e Comarca de Maracaí, e na Rua Cruzeiro do Sul, 10, bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Maracaí/SP, dolosamente e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tinham em depósito e traziam

consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a terceiros, respetivamente, 1 (uma) grande porção de maconha, com peso bruto aproximado de 184,81g; e mais 1 (uma) porção pequena de maconha com peso bruto aproximado de 2,92g, além de R\$ 24,00 em espécie; tudo, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7/8 e laudo de exame químicotoxicológico de fls. 127/129.

Por fim, no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 11h50, em uma plantação de mandioca próximo à Chácara Santana, situada à Estrada das Pitangueira, 100, nesta cidade e Comarca de Maracaí, dolosamente e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a terceiros, 1 (uma) porção de crack, com peso bruto aproximado de 48,97g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 164/165 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 170/172.

Os denunciados foram notificados (fls. 193 e 186) e apresentaram defesas preliminares (fls. 220 e 223/224).

A denúncia aditada foi recebida em 29 de março de 2022 (fls. 182). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e interrogado os acusados (fls. 294/296).

Encerrada a instrução o Ministério Público, em Memoriais, requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia (fls. 302/308).

A defesa, em Memoriais, requereu, a desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, asseverou a inexistência de vínculo subjetivo, estável e permanente para a associação para o tráfico, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, regime inicial aberto, reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 313/322).

Relatei. Decido.

De saída, possível ao magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

É a emendatio libelli, prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Assim, havendo tipificação equivocada por parte do acusador, o Juiz (de ofício) adequa (corrige) o enquadramento legal, sendo indiferente, ainda, se o novo enquadramento irá gerar prejuízo ou benefício para o réu.

Para predito desiderato não há necessidade de aditamento da peça inicial, até porque, como se sabe, o réu se defende dos fatos, não da tipificação jurídica que lhe é imputada.

Assim, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal entendo que é caso de considerar que as condutas narradas no aditamento à denúncia se amoldam ao artigo 33, caput, por duas vezes, e ao artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A materialidade delitiva exsurge comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelos autos de exibição e apreensão de fls. 07/08 e 164/165, pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos da natureza das drogas (fls. 127/129 e 170/172), bem como pela prova oral, coligida sob o crivo do contraditório.

Jamily Mrachna Nunes de Souza, ré, durante a instrução, apresentou versão

semelhante à versão prestada na fase policial (fl. 09), declarou que, na data dos fatos, foi dar uma volta de moto com o marido Caio, que havia emprestado o veículo de um amigo. Emprestou dinheiro da genitora, abasteceram a moto e foram dar uma volta pela cidade. A certa altura, toparam com a polícia militar e Caio empreendeu fuga. Posteriormente, foram abordados pelos agentes. Com a ré foi encontrada a petequeca que tinham pego para fumar e um aparelho celular. Negou ter dito algo sobre informações comprometedoras contidas no aparelho. Ficou chateada porque a mulher perguntou se tinha nota, respondeu que não, afirmou ter adquirido o celular no “muambeiros” por R\$ 500,00 e a policial falou “já era, perdeu o seu celular”, ficou brava e quando ela pediu a senha, falou que não ia dar. Em seguida, CAIO confessou que tinha mais drogas na residência do casal, local em que compareceram os policiais e apreenderam o entorpecente. Caio foi preso no dia 22 e a depoente no dia seguinte. Não sabia nada de crack. Pela denúncia que recebeu, ficou sabendo que haviam enterrado crack em um terreno próximo de sua casa. Não entregou droga nenhuma. Negou ter traficado drogas. Trabalhava com a genitora fazendo lanches e pastéis, e, em troca, a genitora ajudava com contas de luz, internet e comida. Caio fazia “bicos” de pintor. Juntavam dinheiro para comprar as drogas. Não fumavam na residência, pois tinham problemas com os vizinhos.

Caio Henrique Souza de Oliveira, réu, em juízo, apresentou versão semelhante à versão prestada na fase policial (fl. 10), declarou que, na data dos fatos, emprestou a motocicleta de um amigo e saiu com ré JAMILY para “fumar um de quebrada”, beirando a rodovia. Em dado momento, depararam-se com a viatura de polícia. Deram ordem de parada, porém, como estava sem CNH, optou por “dar fuga” dos policiais. Abordado, encontraram uma “peteca” que iam fumar, e, de imediato, o réu prontamente informou ter mais drogas em sua residência, um pedaço maior de maconha. Inclusive, até mostrou para eles onde estava. A maconha seria para o uso pessoal. Reside com JAMILY, a maconha era dos dois. Desconhece a propriedade do crack encontrado no terreno. É perseguido pelos policiais Barauna e Raquel, sendo enquadrado por eles em qualquer lugar da cidade. Já foi preso e processado por tráfico de drogas, contudo, a droga era para uso pessoal, está respondendo ainda. Levou os policiais até a residência e autorizou a entrada. Encontraram a maconha que pegou e entregou em mãos aos policiais, estava na cozinha. Fizeram busca com dois cachorros do canil da policial. A maconha era para uso pessoal. É pintor industrial. Apontou que tinha apetrechos (papelote e isqueiro) para consumir a maconha, porém durante a fuga caiu do seu bolso. Após mostrar foto da residência, apontou que reside após a casa verde. Não consumiu a droga em casa porque ia dar volta com a esposa e ia fumar beirando a rodovia, nas quebradas.

Jorge Henrique Barauna, policial militar, testemunha de acusação, de forma semelhante à versão apresentada em solo policial (fl. 05), em Juízo, relatou que a Polícia Militar recebe inúmeras denúncias da prática de tráfico de drogas pelo casa, as denúncias são recebidas tanto diretamente pela equipe como através do canal 181. Na data dos fatos, visualizaram uma motocicleta sendo conduzida pelo acusado CAIO, tendo como passageira a ré JAMILY, no contrafluxo de direção. Ao realizarem uma manobra com a viatura para realizar abordagem, os acusados empreenderam fuga pelas ruas da cidade, inclusive oferecendo risco aos pedestres. Conseguiram aborda-los na área rural. Com JAMILY foi encontrado entorpecente, um aparelho celular que ela informou ter sido adquirido no “muambeiro” mas que não possuía nota. Questionados se tinha mais drogas na residência, CAIO confirmou que havia mais droga na residência do casal, autorizou a entrada dos policiais no imóvel e mostrou onde estava os entorpecentes. Quanto ao celular, os policiais solicitaram a senha de desbloqueio do aparelho à ré JAMILY, o que foi negado por ela sob o fundamento de que havia conteúdo que a poderia prejudicar. Localizaram drogas com Jamily, era uma porção usada para venda e para uso. Participou de busca na casa deles onde foi localizada quantidade maior de entorpecentes, e, inclusive, Caio que indicou onde estava. Questionaram o Caio durante abordagem se tinha entorpecentes na residência, devido às denúncias que recebiam envolvendo o casal. Inclusive, em data anterior, já tinha apreendido Caio em situação de tráfico. Ele

disse que tinha drogas na residência, autorizou a entrada dos policiais, indicou, salvo engano, o armário da cozinha, onde estava um pedaço maior de maconha e entregou aos policiais. Não participou da busca realizada dias seguintes. O casal foi localizado próximo à residência deles. Evadiram-se em várias ruas, até sair sentido a rodovia e chegar na área rural. Quando realizaram abordagem, estava realizando patrulhamento de rotina. Não fizeram campana na casa dos acusados. Porém, já realizou a prisão de Caio em outra data, pela prática de tráfico de drogas. Em outra prisão, presenciou o acusado vendendo drogas. Não sabe dizer se foram encontrados petrechos para a droga, salvo engano, localizaram plástico filme. Jamily disse que a droga era para uso próprio dela. Tinha uma quantidade em dinheiro mas não era de quantidade expressiva.

Raquel Machado Serra, policial militar, testemunha de acusação, em juízo, prestou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 06), disse que fazia patrulhamento de rotina pelas vias municipais na companhia do PM Barauna, quando, pela Rua Cruzeiro do Sul, avistaram uma motocicleta YBR de cor azul, conduzida pelo réu CAIO com a ré JAMILY na garupa. Foi dada ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e empreendeu fuga. Fizeram acompanhamento por várias ruas de Maracaí, pondo em risco a vida de pessoas que circulavam na via e lograram êxito em alcançar os acusados. Após um tempo, retornaram na rua Cruzeiro do Sul e conseguiram aborda-los. Desembarcaram da motocicleta, não foi localizado nada com Caio, e, em busca pessoal junto a ré, localizou R\$ 24,40 em dinheiro, uma porção de maconha, um aparelho celular Iphone. JAMILY se negou a dar a senha do celular, pois disse que o conteúdo poderia prejudica-la, que tinha adquirido o celular no “muambeiro”, pela quantia de R\$ 500,00. Indagado, CAIO confessou que teria mais droga em sua residência. Foram até o local, foi franqueada a entrada dos policiais por ele, o próprio CAIO quem indicou o local em que guardava uma porção maior de drogas. Pediram apoio do canil mas nada mais foi localizado naquela data. Já conhecia os acusados dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Nunca tinha abordado o casal ou pessoa que tenha adquirido drogas deles. Não encontrou petrechos para o tráfico. Com Jamily, encontrou R\$ 24,40. A casa dos acusados é simples. Segundo os acusados, a motocicleta pertencia a um amigo.

Leandro Cardoso de Sá, policial militar, testemunha de acusação, durante a instrução, apresentou depoimento semelhante ao depoimento prestado durante inquérito policial (fls. 166/167), disse que, posteriormente à prisão em flagrante dos réus, no dia 25 de janeiro do corrente ano, estava de serviço quando recebeu uma denúncia anônima, via 190, que relatava que, ao lado da Chácara Santana, tinha um terreno com plantação de mandioca. O denunciante teria visto, uma semana antes da prisão do casal, JAMILY enterrando porção de droga, exatamente no terceiro “pé de mandioca” da primeira fileira. Com base nas informações, os policiais deslocaram-se até o local apontado e lograram êxito em localizar uma porção grande de droga, aparentando ser crack. O denunciante indicou ter visto JAMILY enterrando a droga, porém informou que o casal praticavam o comércio de entorpecentes. Localizaram drogas conforme a denúncia. O denunciante disse que era rotineira a prática de drogas pelo casal, no local. O terreno situa-se ao lado da residência dos réus. Conhecia os acusados dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. As denúncias indicavam ambos os acusados. Trabalhava em Maracaí há 05 anos. Não prendeu pessoas que tenham adquirido drogas do casal. Já averiguaram denúncias na rua em que residiam. A denúncia de que Jamily teria enterrado drogas foi recebida via 190. À fl. 297 indicou como casa do réu a casa ao lado da casa verde. Pela foto, não conseguiu identificar se é a rua da casa do réu pois as ruas são bem parecidas.

Fernando Henrique Santos Furlaneto, policial militar, testemunha de acusação, de forma semelhante à versão apresentada em solo policial (fls. 168/169), em Juízo, afirmou que recebeu denúncia via COPOM, 190, a qual apontava que em um terreno na Estrada das Pitangueiras havia uma plantação de mandioca e a ré JAMILY teria ido ao

local e escondido entorpecentes em um dos “pés de mandioca”. A equipe foi ao endereço mencionado e localizaram quantidade de crack, embalada em plástico-filme. Trabalha em Paraguaçu Paulista mas estava prestando serviços em Maracaí. A denúncia foi recebida via COPOM, cai via rádio em toda rede. Conhecia Jamily de outras ocorrências, dias antes teve outra ocorrência com o casal. O terreno fica ao lado da casa do casal. Não sabe se moram na casa. A denúncia não indicava o tipo de droga que estava enterrada.

Angela de Oliveira, testemunha de defesa, declarou é vizinha do casal, conhece os réus há muitos anos. São casados, não tem filhos. CAIO é pintor e JAMILY trabalha na lanchonete da família. Sabe que o casal é usuário de drogas, não sabe o tipo da droga que usam. Residem em uma das últimas casas da rua. (Mostradas algumas fotos à depoente), referiu que a casa dos réus fica no meio do quarteirão e não faz fronteira com o terreno em que foi localizado o crack enterrado, situando-se duas casas à direita do referido terreno, ao lado da casa de muro verde. Nunca viu movimentação estranha nos arredores da residência do casal.

Maria Aparecida Ribeiro Souza, testemunha de defesa, informante do juízo, avó de Caio, CAIO é pintor e que os réus são casados. Residem no bairro Vila Nova. A casa fica no começo da estrada e pertence ao pai de Caio. Estão juntos há mais seis anos, não tem filhos. Caio é pintor e Jamily ajuda a mãe na fabricação de lanches caseiros. Ambos os acusados são usuários de drogas, dão muito trabalho pra família. CAIO faz tratamento de drogadição. Indicou o local em que residem os acusados como sendo no meio do quarteirão, na casa de madeira, ao lado da casa verde. Nunca presenciou o tráfico de drogas na residência. Não tem carro e nem moto.

Ana Maria Batista dos Santos, testemunha de defesa, disse que conhece o casal da cidade de Maracaí, residem no bairro Vila Nova, próximo à entrada da estrada. Soube de comentários de terceiros que os réus foram presos. A família dele convidou para prestar depoimento, conhece a genitora da JAMILY. Jamily trabalha junto com a mãe em um cachorro-quente caseiro. CAIO é pintor.

Quanto ao delito de associação criminosa (Lei de Drogas, artigo 35), patente sua ocorrência, melhor sorte não assistindo aos réus.

Os testemunhos dos policiais que realizaram a operação que culminou com a prisão dos acusados foram uníssomos em relação ao encontro das drogas, bem como de que já haviam denúncias de que os acusados estavam associados para a prática do tráfico de drogas.

Inadmissível, portanto, pretender que as palavras isoladas dos acusados, negando os fatos, se sobreponha aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais encarregados de suas prisões.

Ademais, elementos sensíveis e materiais do crime, vestígios, sinais, rastros, marcas, impressões, traços, coincidências, circunstâncias conhecidas e provadas, como na espécie, tendo relação com o fato autorizam, por dedução, concluir-se a existência do delito descrito na denúncia, mesmo porque, o Código de Processo Penal os erigiu à categoria de prova direta.

Confira-se:

"INDÍCIOS - LEI PROCESSUAL PENAL ABRIGA A PROVA INDICIÁRIA (ART. 239, DO CPP). Sua aceitação como meio de prova harmoniza-se com o princípio do livre convencimento do juiz. Embora, para certos autores, a prova indiciária seja incompatível com a exigibilidade de certeza da sentença condenatória, se dela não usarmos grassará, muitas vezes, a impunidade. O que se torna indispensável é ter-se uma cautela maior sempre fundada no conhecimento e prudente critério que é dado ao julgador". (TJSP, in Revista dos Tribunais, v. 718, p. 394).

Assim, como exposto, há evidente animus associativo na espécie pois inegável existência de imediato contato entre os réus, revelando premeditação de condutas, além de nítida divisão de tarefas (note-se, no caso dos autos, quando da prisão {primeira conduta de tráfico, descrita na inicial acusatória}, os acusados saíram de sua respectiva residência {Caio pilotando o motociclo e Jamily na condição de acompanhante}, sendo abordados pelos policiais com droga embalada para entrega). Ou seja, a ligação entre ambos é inequívoca quanto ao comércio espúrio e a ação individual (que não se resume, apenas, no aspecto "abordagem policial") mas anterior à esta (desde a saída da residência) revela prévia finalidade delitiva definida, qual seja, a traficância.

Nesse sentido, o magistério de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

"Elemento subjetivo do tipo - É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração" (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128). - Grifei!

No tocante à primeira conduta de tráfico de drogas, também de rigor a condenação.

O tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 é misto alternativo, de natureza múltipla ou de conteúdo variado, ou seja, todas as condutas nele descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal. Em outras palavras, o crime se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de comercialização da droga.

O que demonstra a prática do tráfico ilícito de drogas é o dolo do agente de transferir ou repassar a droga a usuários, nos termos de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos presentes no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Eis o que estabelece o artigo 33 da Lei de Antidrogas:

"Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

No caso dos autos, a forma de acondicionamento da droga e as denúncias existentes (relatadas pelos policiais em Juízo) permitem concluir que não se destinava ao uso próprio, restando bem evidenciado o tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Oportuno lembrar, ainda, no que concerne ao depoimento prestado pelo policial militar que "a presunção é sempre a favor da autoridade judiciária ou policial. O que se presume é, realmente, a imparcialidade, a correção, a lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é que exige prova. Quem acusa a autoridade de arbitrária, de capaz de coagir para extorquir confissões contra a verdade, de forjar depoimentos, de compelir a assinar o que o réu não disse, está no dever de oferecer provas, pois a acusação é das mais graves, é das mais repugnantes." (Ac. TJ do DF - Ap. crim. 5.371, Rel. Des. José Duarte - Plácido Sá Carvalh.o, CPP, p. 182).

Dessa forma, os testemunhos dos policiais devem prevalecer frente às demais testemunhas.

Não se descure, por fim, no aspecto, que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito o ônus probatório, cabendo, portanto, à defesa, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, na hipótese, predito ônus probandi - pela defesa - não foi satisfeito (CPP, art. 156).

Mutatis mutandis, confira-se:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C O ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A VERSÃO EXCULPATÓRIA DO ACUSADO - LOCAL PONTO DE VENDA DE DROGAS - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, BEM COMO CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO, POLICIAIS QUE PRESENCIARAM O RECORRENTE EM ATITUDE TÍPICA DE VENDA DE ENTORPECENTES, NÃO SE COADUNAM COM USUÁRIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO LOCAL DO CRIME - DESCABIMENTO - CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPO DE FUTEBOL - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PARA TRAFICANTE OCASIONAL - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO FATORES QUE NÃO SE COADUNAM COM AQUELE QUE PRÁTICA O CRIME PELA PRIMEIRA VEZ - RÉU PRESO, APÓS SER SOLTO POR ESTE PROCESSO, POR TRÁFICO. PENAS E REGIME BEM DOSADOS - RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 0090612-04.2018.8.26.0050; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

No tocante à segunda conduta de tráfico, referente à manutenção em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a terceiros de 1 (uma) porção de crack, entendo que a absolvição é imperativa, pois a ré Jamily negou a prática da conduta e nenhuma testemunha presenciou a mesma enterrar a substância entorpecente ao lado do terreno. Dessa forma, o princípio in dubio pro reo deve ser prestigiado.

Referido princípio busca garantir que, sem provas suficientes dos elementos subjetivos e objetivos, do fato típico e ilícito, não seja possível a aplicação de pena. A insuficiência da prova equivale à subsistência de uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou inexistência de determinado fato ou de sua autoria. Dá-se, então, como não provado o fato desfavorável ao arguido, e, vedado o non liquet em nosso ordenamento, é indicado ao juiz que valore a favor do acusado a prova dúbia (MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade de inimputáveis e in dubio pro reo. Coimbra: Coimbra editora, 1997, p. 11).

Destarte, diante da prova colhida, não é possível proferir édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo a absolvição medida impositiva

Passo à dosimetria da pena.

Quanto à ré Jamily Mrachna Nunes de Souza

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. A acusada não possui antecedentes criminais. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua

personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas não foram apreendidas em quantidade e diversidade a justificar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas para o tráfico de drogas e 03 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Em que pese os argumentos da defesa, não há confissão quanto ao tráfico, sendo incabível o reconhecimento da confissão, conforme enunciado da súmula nº 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Presente a agravante da reincidência, conforme certificado às fls. 279/280, referente aos autos sob nº 0001455-98.2010.8.26.0341. Dessa forma, aumento a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas para o tráfico de drogas e 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 816 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico.

Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição. Ante a reincidência e a dedicação à atividades criminosas, ausentes os requisitos do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. Ausentes causas de aumento.

Aplicando-se o concurso material, somo as reprimendas, perfazendo o total de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 1399 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas

Quanto ao réu Caio Henrique Souza de Oliveira

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas não foram apreendidas em quantidade e diversidade a justificar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas para o tráfico de drogas e 03 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes. Em que pese os argumentos da defesa, não há confissão quanto ao tráfico, sendo incabível o reconhecimento da confissão, conforme enunciado da súmula nº 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Ausentes agravantes, permanecem as reprimendas em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas para o tráfico de drogas e 03 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, para o crime de associação para o tráfico.

Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição, porquanto a condenação ao delito de associação para o tráfico torna incompatível o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de dedicação a atividades criminosas. Ausentes causas de aumento.

Aplicando-se o concurso material, somo as reprimendas, perfazendo o total de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Em razão do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para:

(i) na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus Jamily Mrachna Nunes de Souza e Caio Henrique Souza de Oliveira das sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (segundo fato descrito na denúncia).

(ii) CONDENAR Jamily Mrachna Nunes de Souza como incurso nas sanções do artigo 33, caput e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do código Pena à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 1399 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

(iii) CONDENAR Caio Henrique Souza de Oliveira como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Ante o montante da pena aplicada e a reincidência específica, a ré Jamily deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado (cf. artigo 59, III, c.c.artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal).

Caio Henrique Souza de Oliveira deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto (cf. artigo 59, III, c.c.artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).

Ante a quantidade da pena de ambos os acusados e a reincidência da ré Jamily, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal). Além da gravidade concreta da conduta demonstrar que não seria socialmente recomendável. Também em razão do montante da pena de ambos os acusados e da reincidência de Jamily, incabível a concessão de sursis (artigo 77, caput, I do Código Penal).

Deve permanecer sua custódia cautelar, pois não modificadas as situações que demandaram suas necessidades (CPP, art. 387, § 1.º). Trata-se de crime de exacerbada gravidade, que fomenta a criminalidade e discórdia familiar nas grandes e pequenas cidades e coloca em constante desassossego a sociedade e a segurança dos cidadãos de bem. Dessa forma, a decretação da custódia cautelar permanece necessária como medida que se impõe para assegurar a ordem pública.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO

JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Rememore-se o teor do enunciado da súmula 716 do STF: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Determino, portanto, que o acusado Caio Henrique Souza de Oliveira cumpra a pena em estabelecimento adequado ao regime prisional fixado, qual seja, o semiaberto.

Deixo de quantificar o prejuízo sofrido pois trata-se de crime vago (inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal).

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA